

1528540-83.2019.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... da quantidade de moradores de rua e tráfico de drogas. Avistaram o acusado consumindo um cigarro, mas não foi possível identificar se era entorpecente, pois ele se desfez do objeto. Declarou que, após a abordagem, encontraram dois eppendorfs de drogas com o réu e o conduziram à delegacia. Mencionou que o acusado não se explicou, estava agitado e tiveram que algemá-lo. Não conheciam o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1528540-83.2019.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528540-83.2019.8.26.0562 - Controle n.º 358/20

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIANS LOPES DOMICIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

WILLIANS LOPES DOMICIANO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 12 de novembro de 2019, por volta das 9h10min, na Rua Euclides Campos n.º 21, José Menino, neste município e comarca, para uso próprio, trazia consigo substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Diz a denúncia que guardas municipais em operação pelo local depararam-se com dois indivíduos sentados na grama ao lado dos trilhos do VLT. Os indivíduos, ao perceberem a aproximação dos guardas, fizeram menção de fuga, mas foram contidos pelos guardas.

Ao iniciar a revista pessoal, o acusado enfiou a mão no bolso da camisa e rapidamente jogou no chão 2 (dois) flaconetes contendo pó branco em seu interior (cocaína).

A materialidade do delito vem comprovada pelo laudo toxicológico definitivo

acostado aos autos de pp. 32/33 (p. 38/39).

O feito tramitou, inicialmente, no Juizado Especial Criminal desta Comarca, mas o processo foi redistribuído ao juízo comum em razão da não localização do réu para citação pessoal (p. 43).

Recebida a denúncia (pp. 49/50), foi o réu citado por edital (pp. 57 e 58).

Declarou-se suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, na forma do previsto no artigo 366 do Código de Processo Penal (pp. 59/60).

À vista da citação pessoal (p. 106), retomou-se o curso desta ação penal (p. 107).

A Defesa ofereceu a resposta de pp. 112/116, prosseguindo-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 117/118).

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas. Prejudicado o interrogatório, em razão da ausência do réu, declarado revel (pp. 166/167).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na inicial. Além disso, pugnou pela consideração da reincidência na fixação da pena (gravação audiovisual – pp. 166/167).

A Defesa, em suas derradeiras alegações orais, pleiteou a absolvição por atipicidade da conduta, pois o delito imputado não lesou bens jurídicos alheios (gravação audiovisual – pp. 166/167).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade do crime está demonstrada no auto de exibição e apreensão de p. 5 e exame químico toxicológico de pp. 32/33, que confirmam a natureza do material estupefaciente como sendo cocaína.

A autoria do fato delituoso também é certa.

Ao ser ouvido pela autoridade policial, o acusado disse que é usuário de drogas, afirmando que os dois flaconetes encontrados lhe pertenciam. Disse que comprou os entorpecentes na praia de um desconhecido pelo valor de R\$ 10,00 (p. 3).

Em juízo, preferiu a revelia, declarando-se prejudicado o interrogatório (gravação audiovisual – pp. 166/167).

Luiz Gabriel Santos Justino, guarda municipal, referiu que não se recorda das características do réu. Contou que realizavam ação conjunta na região em razão da quantidade de moradores de rua e tráfico de drogas. Avistaram o acusado consumindo um cigarro, mas não foi possível identificar se era entorpecente, pois ele se desfez do objeto. Declarou que, após a abordagem, encontraram dois eppendorfs de drogas com o réu e o conduziram à delegacia. Mencionou que o acusado não se explicou, estava agitado e tiveram que algemá-lo. Não conheciam o réu, que foi visto no local em outra data (gravação audiovisual – pp. 166/167).

Vinicius Figueiredo Vieira, guarda municipal, afirmou que não se recorda do acusado. Na data dos fatos estavam em força tarefa com a Terracom e, perto do túnel, viram o réu fazendo o uso de entorpecente com outra pessoa. Após a abordagem, encontraram uma pequena porção de cocaína. Mencionou que o réu não justificou a conduta e tiveram que utilizar algemas para conduzi-lo. Referiu que é comum o uso de entorpecente no local dos fatos (gravação audiovisual – pp. 166/167).

Vê-se, assim, que a prova amealhada é segura e dá suporte ao desate condenatório, não sendo possível declarar a absolvição.

O acusado admitiu a conduta delituosa em sede policial, afirmando que possuía os dois flaconetes encontrados em seu poder.

Ademais, sob o crivo do contraditório, os guardas municipais foram firmes e coerentes, não se evidenciando mácula no seu relato. Ao revés, de forma isenta, informou os principais detalhes a respeito da abordagem e apreensão de dois eppendorfs de cocaína encontrados em poder do réu.

Desta forma, certo está que a confissão – manifestada na fase policial – encontra seguro conforto na prova aqui reunida sob o contraditório, que indica o desate condenatório.

Por final, destaque-se que não há como reconhecer que a posse ilegal de droga destinada a consumo pessoal seja conduta atípica, em razão de inconstitucionalidade

do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Apura-se conduta delituosa que afronta e põe em risco a saúde pública, evidenciando-se patente o risco social, bem como se revela potencial e abstrato o dano decorrente do consumo de entorpecentes, pouco importando a lesividade configurada pela quantidade de droga apreendida em cada caso concreto. Trata-se, por certo, de norma penal que tutela a saúde pública, sendo irrelevante discutir se a repressão ao consumo de entorpecentes, sem autorização legal, representa invasão à privacidade do cidadão.

Não fosse isso, não há dúvida que deve o Estado criminalizar o consumo ilegal de drogas, já que a saúde pública é posta em risco em razão da conduta individualmente considerada. Essa situação é penalmente relevante e, assim, há de ser reprimida. Vale destacar, ademais, que a pequena quantidade de entorpecentes é característica inerente ao delito em apreço, pois, do contrário, estaríamos diante de forte indício de mercancia.

Neste sentido, extrai-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"PENAL. APELAÇÃO. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por atipicidade da conduta, alegando a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Descabimento. Absolvição. Impossibilidade.

Constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas é típica, não se vislumbrando a alegada violação a quaisquer princípios constitucionais, tais como o da lesividade e da intimidade. Não apenas o uso propriamente que caracteriza mais seriamente o delito, mas a conduta precedente, ou seja, o porte ou o transporte da substância entorpecente para aquela finalidade. O bem jurídico protegido é a saúde pública, em razão do risco que lhe é inerente. A lei não trouxe a descriminalização do porte de drogas para o consumo pessoal, mas apenas a despenalização, a fim de conferir ao usuário de drogas tratamento diverso daquele endereçado ao traficante. Inconstitucionalidade não verificada. O Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, do C. Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a constitucionalidade da criminalização do porte de drogas, está suspenso.

Observância do art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10. Condenação acertada, ora mantida. Negado provimento. " (TJSP; Apelação Criminal 1500037-11.2019.8.26.0608; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 23/06/2020).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PORTE DE ENTORPECENTES PARA FINS DE USO - Denúncia rejeitada sob o fundamento de atipicidade da conduta, ante sua insignificância - Porte de substância proscribida que ofende a saúde pública - Conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas que não foi descriminalizada - Tipo que subsiste em consonância com as normas e princípios constitucionais, ainda que não positivados - Pequena quantidade de drogas que é característica do tipo penal em testilha - Recurso provido, com determinação. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1506097-52.2018.8.26.0602; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 28/10/2020).

Nesse mesmo sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"... É inviável a declaração da atipicidade da conduta do paciente pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Embora a constitucionalidade do referido artigo esteja afetada na Suprema Corte, diante do reconhecimento da repercussão geral (Tema 505), nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/RG, ainda prevalece neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não houve a descriminalização do porte de drogas para uso próprio com a entrada em vigor da Lei n. 11.343/2006, mas mera despenalização, tendo em vista a previsão de penas alternativas para o infrator..." (HC 535.785/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019).

Outrossim, extrai-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"... A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) nenhuma periculosidade social da ação; (III) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III - No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de

entorpecente é crime de perigo presumido. IV – É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V – A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetivos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI – Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII – Habeas corpus prejudicado." (HC 102940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 15/02/2011).

Por assim ser, em sendo firme e seguro o contexto probatório, notadamente a prova produzida sob o crivo do contraditório, há suporte indicando o desate condenatório, reconhecendo-se a prática do delito de porte de droga, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Procede, portanto, o pedido inicial.

Passo à individualização da pena.

O acusado é reincidente, pois definitivamente condenado pela prática de furto qualificado (autos n.º 0018745-06.2014.8.26.0562 - certidão de pp. 181/182).

Ademais, ostenta condenação definitiva antiga pelo crime de tráfico de drogas (autos n.º 0017728-42.2008.8.26.0562 - certidão de p. 181).

Outrossim, o acusado se vê processado em duas ações penais por crimes de furto qualificado (autos n.º 1500562-10.2022.8.26.0536 - certidão de p. 182/183) e roubo majorado (autos n.º 1522469-78.2019.8.26.0590 - certidão de p. 183).

Diante das penas enumeradas na legislação, imponho ao réu a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo período de 10 (dez) meses, pena essa que torno definitiva por não haver circunstância que a modifique.

Observo que não é caso de se impor ao acusado a pena de advertência sobre os efeitos da droga, e isso porque não parece que a medida mencionada seja suficiente e necessária à reprovação da conduta aqui apurada.

Note-se que o réu já se viu envolvido até mesmo com tráfico de entorpecentes em outra ocasião, razão pela qual essa medida parece inócua para a reinserção social e percepção dos maléficos efeitos do consumo de drogas.

Aliás, essa medida revela-se inadequada, principalmente porque o réu se declara usuário de drogas e a advertência não surtirá efeito algum sobre seu comportamento, sendo importante considerar que a legislação prima pela prescrição de "...medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção do usuário e dependente de drogas..." (artigo 1º, caput, da Lei nº 11.343/06).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar WILLIANS LOPES DOMICIANO, qualificado nos autos, à pena de 10 (dez) meses de prestação de serviços à comunidade, pena essa a ser cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, por incurso nas sanções previstas no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, arcará o réu com custas processuais correspondentes a 100 (cem) UFESP'S, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Entretanto, e tratando-se de réu a quem se nomeou Defensor Público, é de se presumir que não tenha condições de arcar com o pagamento de custas, razão pela qual há de se observar o previsto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Anotar-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 31 de outubro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA